



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 2009839 - MG (2022/0193425-3)

RELATOR : MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO : GLEISON PINHEIRO DE JESUS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a *"entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados"*

2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que *"a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar"* (SEXTA TURMA, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017).

3. No caso em tela, o ingresso na casa onde foram apreendidas as drogas –16g (dezesseis gramas) de maconha e 1g (um grama) de cocaína – e o rádio comunicador não teve fundadas razões, ao contrário, porquanto a expedição de mandado de busca e apreensão de menor não autoriza o ingresso no domicílio e a realização de varredura no local.

4. Cumpre consignar, por oportuno, que o art. 283, § 2º, do CPP determina, expressamente, que em cumprimento de mandado de prisão – ou busca e apreensão de menor, como no caso em tela –, *"[a] prisão poderá ser efetuada em qualquer dia e a qualquer hora, respeitadas as restrições relativas à inviolabilidade do domicílio"*, o que demonstra a ilegalidade da presente diligência porquanto os próprios agentes policiais informaram que

perceberam a presença do rádio comunicador quando **já estavam dentro da residência.**

5. **"Segundo a nova orientação jurisprudencial, o ônus de comprovar a higidez dessa autorização, com prova da voluntariedade do consentimento, recai sobre o estado acusador"** (HC n. 685.593/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 19/10/2021, grifei.)

6. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Sexta Turma, por maioria, negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Vencida a Sra. Ministra Laurita Vaz.

Brasília, 09 de maio de 2023.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 2009839 - MG (2022/0193425-3)

RELATOR : MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO : GLEISON PINHEIRO DE JESUS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a *"entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados"*

2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que *"a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar"* (SEXTA TURMA, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017).

3. No caso em tela, o ingresso na casa onde foram apreendidas as drogas – 16g (dezesseis gramas) de maconha e 1g (um grama) de cocaína – e o rádio comunicador não teve fundadas razões, ao contrário, porquanto a expedição de mandado de busca e apreensão de menor não autoriza o ingresso no domicílio e a realização de varredura no local.

4. Cumpre consignar, por oportuno, que o art. 283, § 2º, do CPP determina, expressamente, que em cumprimento de mandado de prisão – ou busca e apreensão de menor, como no caso em tela –, *"[a] prisão poderá ser efetuada em qualquer dia e a qualquer hora, respeitadas as restrições relativas à inviolabilidade do domicílio"*, o que demonstra a ilegalidade da presente diligência porquanto os próprios agentes policiais informaram que perceberam a presença do rádio comunicador quando **já estavam dentro da residência**.

5. "Segundo a nova orientação jurisprudencial, o ônus de comprovar a higidez dessa autorização, com prova da voluntariedade do consentimento, recai sobre o estado acusador" (HC n. 685.593/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 19/10/2021, grifei.)

6. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Trata-se de agravo regimental em recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL contra decisão em que dei provimento ao recurso em *decisum* assim relatado:

Trata-se de recurso especial interposto por GLEISON PINHEIRO DE JESUS com fundamento no art. 105, inciso III, "a", da Constituição Federal de 1988 contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Consta dos autos que o recorrente foi condenado a 2 anos de reclusão, no regime aberto, substituída a pena corporal por restritivas de direitos, pela prática dos delitos de porte de drogas para consumo próprio, 16g (dezesseis gramas) de maconha e 1g (um grama) de cocaína (e-STJ fl. 1), e colaboração com grupo criminoso voltado para a prática de tráfico de drogas (e-STJ fl. 204).

Em apelação criminal manejada pela defesa, a sentença foi mantida em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 272):

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 28 E 37 DA LEI 11.343/06. CRIME DE USO DE DROGAS. CONSTITUCIONALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. NULIDADE PROCESSUAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ILICITUDE DA QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS. AFASTAMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. INFORMANTE DO TRÁFICO. DELITO TIPIFICADO. PLEITO CONCERNENTE À ABSOLVIÇÃO INVIABILIZADO. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 28-A DO CP, INCLUÍDO PELA LEI N. 13.964/2019. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

- Não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343/06, com base na inexistência de lesividade, porquanto o dispositivo tutela a saúde pública, sendo a lesividade apurada em cada caso concreto irrelevante.

- Não há qualquer ilegalidade no ingresso dos policiais na residência do réu a fim de cumprir mandado de busca e apreensão, devendo ser rejeitada a preliminar de nulidade por invasão de domicílio.

- Extraíndo-se dos autos elementos de convicção aptos a comprovarem a perpetração do delito descrito no art. 37 da Lei 11.343/06 pelo apelante, resta inviabilizado o pleito absolutório.

- Descabida a aplicação retroativa do instituto previsto no art. 28-A do CP (acordo de não persecução penal), inserido pela Lei n. 13.964/2019, quando a persecução penal se encerrou, encontrando-se o feito já sentenciado quando da entrada em vigor da referida lei.

Irresignada, a defesa então interpôs o presente recurso especial, alegando

ofensa ao art. 240 do Código de Processo Penal e ao art. 37 da Lei de Drogas.

Alega ser ilegal a realização de busca domiciliar quando autorizada somente busca e apreensão de menor (e-STJ fl. 291).

Acrescenta ser ilegal a condenação pelo tipo previsto no art. 37 da Lei de Drogas em razão de não ter sido comprovada a existência de grupo criminoso voltado para a prática (e-STJ fl. 295).

Requeru, portanto, a reforma do acórdão atacado para anular o feito desde a busca domiciliar ilegal ou a absolvição pelo delito do art. 37 da LAD (e-STJ fl. 297).

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso especial (e-STJ fls. 334/338).

No presente agravo, alega a parte que havia fundadas razões para o ingresso no domicílio e que a entrada foi autorizada.

Requer, por fim, a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo colegiado.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

A irresignação não merece prosperar.

Cinge-se a controvérsia a verificar a existência de "fundadas razões" que, consoante o entendimento da Suprema Corte, autorizem a entrada forçada em domicílio, prescindindo-se de mandado de busca e apreensão.

Colaciono, oportunamente, este trecho da denúncia (e-STJ fl. 2):

Segundo se apurou, nas condições de tempo e lugar acima descritas, Policiais Militares, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos de execução de nº 0024.17.045.400-3 pelo Dr. Afrânio José Fonseca Nardy, se deslocaram juntamente com a Polícia Civil, em operação conjunta, para o endereço informado no mandado em desfavor do denunciado Gleison Pinheiro de Jesus.

Chegando no imóvel, a guarnição policial foi recebida por Flávia Pinheiro de Jesus e pelo denunciado Gleison, os quais foram informados do motivo da presença policial.

Ato contínuo, assim que os militares começaram a adentrar a residência, a guarnição policial escutou o som de um rádio comunicador que estava em cima de uma televisão, sendo facialmente visualizado.

No caso em exame, verifica-se violação do art. 157 do Código de Processo Penal, observado que o ingresso na casa onde foram apreendidas as drogas e o rádio

comunicador não teve fundadas razões, ao contrário, porquanto a expedição de mandado de busca e apreensão de menor não autoriza o ingresso no domicílio, conforme se extrai do preceito legal:

Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

§ 1º Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:

- a) prender criminosos;*
- b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;*
- c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;*
- d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;*
- e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;*
- f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;*
- g) apreender pessoas vítimas de crimes;*
- h) colher qualquer elemento de convicção.*

Assim sendo, o contexto fático narrado não corrobora a conclusão inarredável de que na residência praticava-se qualquer tipo de delito que autorizasse a entrada ao domicílio.

Nesse contexto, é importante destacar que a Sexta Turma desta Corte, em recente entendimento firmado nos autos do HC n. 598.051/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, fixou as teses de que "*as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente*", e de que até mesmo o consentimento, registrado nos autos, para o ingresso das autoridades públicas sem mandado deve ser comprovado pelo Estado.

Eis a íntegra da ementa do mencionado julgado:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.

1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

1.1 A inviolabilidade de sua morada é uma das expressões do direito à intimidade do indivíduo, o qual, sozinho ou na companhia de seu grupo familiar, espera ter o seu espaço íntimo preservado contra devassas indiscriminadas e arbitrárias, perpetradas sem os cuidados e os limites que a excepcionalidade da ressalva a tal franquia constitucional exige.

1.2. O direito à inviolabilidade de domicílio, dada a sua magnitude e seu relevo, é salvaguardado em diversos catálogos constitucionais de direitos e garantias fundamentais. Célebre, a propósito, a exortação de Conde Chatham, ao dizer que: "O homem mais pobre pode em sua cabana desafiar todas as forças da Coroa. Pode ser frágil, seu telhado pode tremer, o vento pode soprar por ele, a tempestade pode entrar, a chuva pode entrar, mas o Rei da Inglaterra não pode entrar!" ("The poorest man may in his cottage bid defiance to all the forces of the Crown. It may be frail, its roof may shake, the wind may blow through it, the storm may enter, the rain may enter, but the King of England cannot enter!" William Pitt, Earl of Chatham. Speech, March 1763, in Lord Brougham Historical Sketches of Statesmen in the Time of George III First Series (1845) v. 1).

2. O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

2.1. Somente o flagrante delito que traduza verdadeira urgência legítima o ingresso em domicílio alheio, como se infere da própria Lei de Drogas (L. 11.343/2006, art. 53, II) e da Lei 12.850/2013 (art. 8º), que autorizam o retardamento da atuação policial na investigação dos crimes de tráfico de entorpecentes, a denotar que nem sempre o caráter permanente do crime impõe sua interrupção imediata a fim de proteger bem jurídico e evitar danos; é dizer, mesmo diante de situação de flagrância delitiva, a maior segurança e a melhor instrumentalização da investigação - e, no que interessa a este caso, a proteção do direito à inviolabilidade do domicílio - justificam o retardo da cessação da prática delitiva.

2.2. A autorização judicial para a busca domiciliar, mediante mandado, é o caminho mais acertado a tomar, de sorte a se evitarem situações que possam, a depender das circunstâncias, comprometer a licitude da prova e, por sua vez, ensejar possível responsabilização administrativa, civil e penal do agente da segurança pública autor da ilegalidade, além, é claro, da anulação - amiúde irreversível - de todo o processo, em prejuízo da sociedade.

3. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), a tese de que: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). Em conclusão a seu voto, o relator salientou que a interpretação jurisprudencial sobre o tema precisa evoluir, de sorte a trazer mais segurança tanto para os indivíduos sujeitos a tal medida invasiva quanto para os policiais, que deixariam de assumir o risco de cometer crime de invasão de domicílio ou de abuso de autoridade, principalmente quando a diligência não tiver alcançado o resultado esperado.

4. As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude "suspeita", ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente.

5. Se, por um lado, práticas ilícitas graves autorizam eventualmente o sacrifício de direitos fundamentais, por outro, a coletividade, sobretudo a integrada por segmentos das camadas sociais mais precárias economicamente, excluídas do usufruto pleno de sua cidadania, também precisa sentir-se segura e ver preservados seus mínimos direitos e garantias constitucionais, em especial o de não ter a residência invadida e devassada, a qualquer hora do dia ou da noite, por agentes do Estado, sem as cautelas devidas e sob a única justificativa, não amparada em elementos concretos de convicção, de que o local supostamente seria, por exemplo, um ponto de tráfico de drogas, ou de que o suspeito do tráfico ali se homiziou.

5.1. Em um país marcado por alta desigualdade social e racial, o policiamento ostensivo tende a se concentrar em grupos marginalizados e considerados potenciais criminosos ou usuais suspeitos, assim definidos por fatores subjetivos, como idade, cor da pele, gênero, classe social, local da residência, vestimentas etc.

5.2. Sob essa perspectiva, a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos - diante da discricionariedade policial na identificação de suspeitos de práticas criminosas - pode fragilizar e tornar irritado o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar, a qual protege não apenas o suspeito, mas todos os moradores do local.

5.3. Tal compreensão não se traduz, obviamente, em cercear a necessária ação das forças de segurança pública no combate ao tráfico de entorpecentes, muito menos em transformar o domicílio em salvaguarda de criminosos ou em espaço de criminalidade. Há de se convir, no entanto, que só justifica o ingresso policial no domicílio alheio a situação de ocorrência de um crime cuja urgência na sua cessação desautorize o aguardo do momento adequado para, mediante mandado judicial - meio ordinário e seguro para o afastamento do direito à inviolabilidade da morada - legitimar a entrada em residência ou local de abrigo.

6. Já no que toca ao consentimento do morador para o ingresso em sua residência - uma das hipóteses autorizadas pela Constituição da República para o afastamento da inviolabilidade do domicílio - outros países trilham caminho judicial mais assertivo, ainda que, como aqui, não haja normatização detalhada nas respectivas Constituições e leis, geralmente limitadas a anunciar o direito à inviolabilidade da intimidade domiciliar e as possíveis autorizações para o ingresso alheio.

6.1. Nos Estados Unidos, por exemplo, a par da necessidade do exame da causa provável para a entrada de policiais em domicílio de suspeitos de crimes, não pode haver dúvidas sobre a voluntariedade da autorização do morador (*in dubio libertas*). O consentimento "deve ser inequívoco, específico e conscientemente dado, não contaminado por qualquer truculência ou coerção" ("consent, to be valid, 'must be unequivocal, specific and intelligently given, uncontaminated by any duress or coercion"). (*United States v McCaleb*, 552 F2d 717, 721 (6th Cir 1977), citando *Simmons v Bomar*, 349 F2d 365, 366 (6th Cir 1965). Além disso, ao Estado cabe o ônus de provar que o consentimento foi, de fato, livre e voluntariamente dado, isento de qualquer forma, direta ou indireta, de coação, o que é aferível pelo teste da totalidade das circunstâncias (*totality of circumstances*).

6.2. No direito espanhol, por sua vez, o Tribunal Supremo destaca, entre outros, os seguintes requisitos para o consentimento do morador: a) deve ser prestado por pessoa capaz, maior de idade e no exercício de seus direitos; b) deve ser consciente e livre; c) deve ser documentado; d) deve ser expresso, não servindo o silêncio como consentimento tácito.

6.3. Outrossim, a documentação comprobatória do assentimento do morador é exigida, na França, de modo expresso e mediante declaração escrita à mão do morador, conforme norma positivada no art. 76 do Código de Processo Penal; nos EUA, também é usual a necessidade de assinatura de um formulário pela pessoa que consentiu com o ingresso em seu domicílio (North Carolina v. Butler (1979) 441 U.S. 369, 373; People v. Ramirez (1997) 59 Cal.App.4th 1548, 1558; U.S. v. Castillo (9a Cir. 1989) 866 F.2d 1071, 1082), declaração que, todavia, será desconsiderada se as circunstâncias indicarem ter sido obtida de forma coercitiva ou houver dúvidas sobre a voluntariedade do consentimento (Haley v. Ohio (1947) 332 U.S. 596, 601; People v. Andersen (1980) 101 Cal.App.3d 563, 579).

6.4. Se para simplesmente algemar uma pessoa, já presa - ostentando, portanto, alguma verossimilhança do fato delituoso que deu origem a sua detenção -, exige-se a indicação, por escrito, da justificativa para o uso de tal medida acautelatória, seria então, no tocante ao ingresso domiciliar, "necessário que nós estabeleçamos, desde logo, como fizemos na Súmula 11, alguma formalidade para que essa razão excepcional seja justificada por escrito, sob pena das sanções cabíveis" (voto do Min. Ricardo Lewandowski, no RE n. 603.616/TO).

6.5. Tal providência, aliás, já é determinada pelo art. 245, § 7º, do Código de Processo Penal - analogicamente aplicável para busca e apreensão também sem mandado judicial - ao dispor que, "[f]inda a diligência, os executores lavrarão auto circunstanciado, assinando-o com duas testemunhas presenciais, sem prejuízo do disposto no § 4º".

7. São frequentes e notórias as notícias de abusos cometidos em operações e diligências policiais, quer em abordagens individuais, quer em intervenções realizadas em comunidades dos grandes centros urbanos. É, portanto, ingenuidade, academicismo e desconexão com a realidade conferir, em tais situações, valor absoluto ao depoimento daqueles que são, precisamente, os apontados responsáveis pelos atos abusivos. E, em um país conhecido por suas práticas autoritárias - não apenas históricas, mas atuais -, a aceitação desse comportamento compromete a necessária aquisição de uma cultura democrática de respeito aos direitos fundamentais de todos, independentemente de posição social, condição financeira, profissão, local da moradia, cor da pele ou raça.

7.1. Ante a ausência de normatização que oriente e regule o ingresso em domicílio alheio, nas hipóteses excepcionais previstas no Texto Maior, há de se aceitar com muita reserva a usual afirmação - como ocorreu no caso ora em julgamento - de que o morador anuiu livremente ao ingresso dos policiais para a busca domiciliar, máxime quando a diligência não é acompanhada de documentação que a imunize contra suspeitas e dúvidas sobre sua legalidade.

7.2. Por isso, avulta de importância que, além da documentação escrita da diligência policial (relatório circunstanciado), seja ela totalmente registrada em vídeo e áudio, de maneira a não deixar dúvidas quanto à legalidade da ação estatal como um todo e, particularmente, quanto ao livre consentimento do morador para o ingresso domiciliar. Semelhante providência resultará na diminuição da criminalidade em geral - pela maior eficácia probatória, bem como pela intimidação a abusos, de um lado, e falsas acusações contra policiais, por outro - e permitirá avaliar se houve, efetivamente, justa causa para o ingresso e, quando indicado ter havido consentimento do morador, se foi ele livremente prestado.

8. Ao Poder Judiciário, ante a lacuna da lei para melhor regulamentação do tema, cabe responder, na moldura do Direito, às situações que, trazidas por provocação do interessado, se mostrem violadoras de direitos fundamentais do indivíduo. E, especialmente, ao Superior Tribunal de Justiça compete, na sua função judicante, buscar a melhor interpretação possível da lei federal, de sorte a não apenas responder ao pedido da parte, mas também formar precedentes que orientem o julgamento de casos futuros similares.

8.1. As decisões do Poder Judiciário - mormente dos Tribunais incumbidos de interpretar, em última instância, as leis federais e a Constituição - servem para dar resposta ao pedido no caso concreto e também para "enriquecer o estoque das regras jurídicas" (Melvin Eisenberg. *The nature of the common law*. Cambridge: Harvard University Press, 1998. p. 4) e assegurar, no plano concreto, a realização dos valores, princípios e objetivos definidos na Constituição de cada país. Para tanto, não podem, em nome da maior eficiência punitiva, tolerar práticas que se divorciam do modelo civilizatório que deve orientar a construção de uma sociedade mais igualitária, fraterna, pluralista e sem preconceitos.

8.2. Como assentado em conhecido debate na Suprema Corte dos EUA sobre a admissibilidade das provas ilícitas (*Weeks v. United States*, 232 U.S. 383, 1914), se os tribunais permitem o uso de provas obtidas em buscas ilegais, tal procedimento representa uma afirmação judicial de manifesta negligência, se não um aberto desafio, às proibições da Constituição, direcionadas à proteção das pessoas contra esse tipo de ação não autorizada ("such proceeding would be to affirm by judicial decision a manifest neglect, if not an open defiance, of the prohibitions of the Constitution, intended for the protection of the people against such unauthorized action").

8.3. A situação versada neste e em inúmeros outros processos que aportam a esta Corte Superior diz respeito à própria noção de civilidade e ao significado concreto do que se entende por Estado Democrático de Direito, que não pode coonestar, para sua legítima existência, práticas abusivas contra parcelas da população que, por sua topografia e status social e econômico, costumam ficar mais suscetíveis ao braço ostensivo e armado das forças de segurança.

9. Na espécie, não havia elementos objetivos, seguros e racionais que justificassem a invasão de domicílio do suspeito, porquanto a simples avaliação subjetiva dos policiais era insuficiente para conduzir a diligência de ingresso na residência, visto que não foi encontrado nenhum entorpecente na busca pessoa realizada em via pública.

10. A seu turno, as regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes castrenses de que o paciente teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor.

11. Assim, como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova derivada de conduta ilícita - no caso, a apreensão, após invasão desautorizada da residência do paciente, de 109 g de maconha -, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão de drogas.

12. Habeas Corpus concedido, com a anulação da prova decorrente do ingresso desautorizado no domicílio e consequente absolvição do paciente, dando-se ciência do inteiro teor do acórdão aos Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, bem como às Defensorias Públicas dos Estados e da União, ao Procurador-Geral da República e aos Procuradores-Gerais dos Estados, aos Conselhos

Nacionais da Justiça e do Ministério Público, à Ordem dos Advogados do Brasil, ao Conselho Nacional de Direitos Humanos, ao Ministro da Justiça e Segurança Pública e aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal, encarecendo a estes últimos que deem conhecimento do teor do julgado a todos os órgãos e agentes da segurança pública federal, estadual e distrital.

13. Estabelece-se o prazo de um ano para permitir o aparelhamento das polícias, treinamento e demais providências necessárias para a adaptação às diretrizes da presente decisão, de modo a, sem prejuízo do exame singular de casos futuros, evitar situações de ilicitude que possam, entre outros efeitos, implicar responsabilidade administrativa, civil e/ou penal do agente estatal. (HC n. 598.051/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 15/3/2021, grifei.)

Diante de todo o exposto, **nego provimento** ao agravo regimental.

É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 2009839 - MG (2022/0193425-3)

RELATOR : MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO : GLEISON PINHEIRO DE JESUS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

VOTO VENCIDO

A EXMA. SRA. MINISTRA LAURITA VAZ:

Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL contra a decisão que deu provimento ao recurso especial interposto pela Defesa para anular as provas colhidas mediante ingresso desautorizado no domicílio e as delas derivadas.

Em seu voto, o Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO manteve a decisão atacada, reiterando o fundamento de que o ingresso na casa onde foram apreendidas as drogas e o rádio comunicador não teve fundadas razões.

No entanto, pedindo vênias ao eminente Relator, entendo ser hipótese de provimento do agravo regimental.

Consta dos autos que o Agravado foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, mais o pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, além de 2 (dois) meses de prestação de serviços à comunidade, em razão da prática dos crimes previstos nos arts. 28 e 37, ambos da Lei n. 11.343/2006. Foram apreendidos, entre outros objetos, **16g de maconha, 1g de cocaína e um rádio comunicador.**

Contra a sentença a Defesa interpôs apelação, que não foi provida (fls. 272-283).

Nas razões do recurso especial, a Defesa pugnou pela declaração de "*nulidade da prova obtida mediante busca domiciliar, tendo em mira os artigos 157, caput, e § 1º, e 240, § 1º, do Código de Processo Penal*" (fl. 297), bem como requereu a absolvição do "*recorrente de todas as imputações que lhe foram dirigidas. Subsidiariamente, em caso da manutenção da r. sentença, requer[eu] a absolvição quanto à imputação do artigo 37 da Lei 11.343/06 diante da falta de provas*" (fl. 297).

O apelo nobre foi admitido (fls. 317-320).

O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso especial (fls. 334-338).

A decisão de fls. 340-348 deu provimento ao recurso especial para anular as provas

colhidas mediante ingresso desautorizado no domicílio e as delas derivadas.

No agravo regimental de fls. 354-360, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL argumenta que *"o ingresso no domicílio não ocorreu para cumprimento de mandado de busca e apreensão de menor, mas em razão das fundadas razões da prática delitiva. Os policiais adentraram na residência após ouvirem o rádio comunicador, usado para informar aos traficantes da movimentação dos policiais, conforme descrito na sentença condenatória (fls. 198/199)"* (fl. 359).

Assevera que *"consta dos autos que o ingresso no domicílio foi autorizado por Flávia Pinheiro de Jesus e por Gleison Pinheiro de Jesus. Assim, não há que se falar em nulidade do ingresso no domicílio do paciente, considerando que, além das fundadas razões evidenciadas no caso concreto, o acusado autorizou a entrada dos agentes"* (fl. 359).

Pugna pelo desprovimento do recurso especial.

Pois bem.

O Juízo singular, ao condenar o Agravado pela prática dos crimes dos arts. 28 e 37 da Lei n. 11.343/2006, ressaltou o seguinte (fl. 201; sem grifos no original):

*"A partir da análise feita acerca dos depoimentos dos policiais ouvidos em juízo é possível inferir que o réu ostentava a condição de olheiro do tráfico de drogas, pelo que **em sua residência foi apreendido um rádio comunicador em funcionamento no exato momento da abordagem policial, tal como será a seguir demonstrado.***

[...]

*Outrossim, em que pese os policiais não haverem visualizado traficantes evadindo durante a operação, nota-se que **o policial Vitor de Jesus afirmou, de forma incontestada, que ao encontrar o rádio comunicador na residência do réu, este estava em funcionamento, pelo que pôde escutar conversas advindas do aparelho relacionadas à função de olheiro do tráfico.***

Lado outro, e considerando os depoimentos colhidos nos autos, válido é o seguinte questionamento: qual seria a finalidade de um rádio comunicador a ser utilizado em local de intensa mercancia de drogas senão a de alertar os traficantes da região acerca da presença policial no local?

Finalmente, a análise do depoimento prestado pelo acusado em sede extrajudicial a informar que possui a função de olheiro, pelo que avisa os traficantes da região acerca da chegada de policiais no local, havendo indicado, ainda, a quantia monetária que recebe em decorrência de tal atuação, demonstra, de forma segura, que o réu praticou a conduta tipificada no art. 37 da Lei n.º 11.343/06."

O Tribunal de origem reconheceu a legalidade da diligência policial nos seguintes termos (fls. 276-278; sem grifos no original):

"Por fim, deve ser afastada a alegação de nulidade das buscas realizadas pelos policiais na residência do réu, pois tal medida se deu em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos nº 0024.17.045400-3, consoante se verifica da decisão de fl. 37 do referido processo, cuja cópia fora anexada a presente ação penal (mídia de fl. 133). Além disso, importante ressaltar que a expedição de mandado de busca e apreensão não se afigura necessária nas hipóteses de flagrante de crime permanente, ex vi do disposto no art. 50, XI, da CR/88.

[...]

Ao serem ouvidas em juízo, as testemunhas ratificaram o Boletim de Ocorrência e confirmaram terem presenciado, no momento da apreensão do rádio comunicador, o réu confessar que trabalha como 'olheiro do tráfico', utilizando-se do aparelho para alertar os traficantes locais acerca da presença da polícia (mídia à fl. 64).

Dessa forma, comprovada, de forma inequívoca, a prática do crime elencado no art. 37 da Lei 11.343/06 pelo apelante, resta inviabilizada a edição de decreto absolutório."

Consta dos autos que o Acusado (enquanto menor) descumpriu medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade. Assim, foi expedido mandado de busca e apreensão para apresentação e condução do infante para apresentar justificativa. Quando do cumprimento do mandado, o Paciente já havia completado 18 (dezoito) anos de idade.

Da acurada leitura dos fundamentos expostos na sentença e no acórdão proferido pelo Tribunal de origem, parece-me inadequado concluir que a polícia não poderia ingressar no domicílio do Réu para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido contra ele.

Constata-se que houve, na hipótese, o encontro fortuito de provas, pois, durante o cumprimento do mandado, os policiais escutaram o som de um rádio comunicador que estava em cima de uma televisão na sala, ou seja, podia ser facilmente visualizado.

A propósito, como bem destacado pelo Magistrado singular, *"em que pese os policiais não haverem visualizado traficantes evadindo durante a operação, nota-se que o policial Vitor de Jesus afirmou, de forma incontestada, que ao encontrar o rádio comunicador na residência do réu, este estava em funcionamento, pelo que pôde escutar conversas advindas do aparelho relacionadas à função de olheiro do tráfico"* (fl. 201; sem grifos no original).

Não se pode, desse modo, admitir que houve desvirtuamento da finalidade no cumprimento do ato inicial (mandado de busca e apreensão), pois o rádio comunicador estava visível na sala e os policiais, ao que consta, puderam escutar conversas advindas do aparelho referentes ao exercício da função de olheiro do tráfico, o que legitimou a diligência realizada pelos agentes públicos (apreensão do referido objeto e das drogas encontradas na residência).

Ao flagrar a prática delitiva, era dever dos policiais atuar, ainda que de ofício, para coibi-la e comunicá-la aos órgãos competentes, sob pena de prevaricação.

Com efeito, *"[a] jurisprudência desta Corte é firme no sentido da adoção da teoria do encontro fortuito ou casual de provas (serendipidade). Segundo essa teoria, independentemente da ocorrência da identidade de investigados ou réus, consideram-se válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes da persecução penal, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de obtenção de prova de outro delito regularmente autorizadas, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado e este não cumpra os requisitos autorizadores da medida probatória, desde que não haja desvio de finalidade na execução do meio de obtenção de prova"* (HC 376.927/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 25/10/2017).

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DOS ARTS. 241-A E 241-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. VALIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO À INTIMIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

[...]

6. *Tendo o ingresso policial no domicílio do réu sido regularmente autorizado por meio de mandado de busca e apreensão expedido com lastro em decisão judicial fundamentada e, na ocasião da busca, sido o agente flagrado enquanto cometia os crimes apurados, baixando e compartilhando material de pornografia infantil, não há falar em violação ao direito à intimidade.*

7. *Concluindo a Corte de origem que o material apreendido fora submetido à polícia científica, a reversão das premissas fáticas esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.*

8. *Agravo regimental provido para conhecer do agravo. Recuso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido." (AgRg no AREsp n. 1.962.521/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022; sem grifos no original.)*

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ILICITUDE DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCONTRO FORTUITO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CRIME PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. *Não há ilicitude a ser declarada quando ocorre a descoberta de fatos por meio do encontro fortuito de provas, ocorrido por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão determinado pelo Juízo competente e de acordo com os requisitos previstos no art. 243 do Código de Processo Penal. Precedentes.*

[...]

4. *Recurso desprovido. Outrossim, em face do julgamento do presente recurso, JULGO PREJUDICADA a análise da petição n.º 00532802/2018." (RHC n. 95.659/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 10/12/2018; sem grifos no original.)*

Dessa forma, **dadas as peculiaridades do caso concreto antes explicitadas**, não há falar em ilicitude da prova amealhada e, por conseguinte, a condenação do Agravado deve ser mantida incólume.

Ante o exposto, pedindo vênias ao eminente Relator, DOU PROVIMENTO ao agravo regimental para reconhecer a litude das provas obtidas mediante o ingresso em domicílio, bem como todas as que delas derivaram.

É como voto.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA**

Número Registro: 2022/0193425-3

AgRg no
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.009.839 / MG
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem: 10024181148719002 11487196520188130024

PAUTA: 17/04/2023

JULGADO: 09/05/2023

Relator

Exmo. Sr. Ministro **ANTONIO SALDANHA PALHEIRO**

Presidente da Sessão

Exma. Sra. Ministra LAURITA VAZ

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Secretário

Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : GLEISON PINHEIRO DE JESUS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO : GLEISON PINHEIRO DE JESUS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Sexta Turma, por maioria, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDF), Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Vencida a Sra. Ministra Laurita Vaz.